

1501357-98.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... para transporte da droga para fins de tráfico, obtendo o entorpecente em São José dos Campos, sendo presos quando retornaram para Monteiro Lobato. Não adquiriu droga na oportunidade para seu uso, que é feito eventualmente (arquivo digital).

NATANAEL, em juízo, também confessou a prática do tráfico, dizendo que obteve a droga em São José dos Campos para venda em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501357-98.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501357-98.2021.8.26.0617 2021/000808

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATANAEL DOS SANTOS SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA e NATANAEL DOS SANTOS SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 08.10.2021, por volta das 01h30min, na Praça Comendador Freire, Rural, Monteiro Lobato, nesta comarca, agindo em concurso de agentes, transportavam e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 37,27g de cocaína, em 51 pinos plásticos; e 3,6g de crack, em 25 pedras.

Notificados os acusados para apresentação de defesa preliminar (fls. 131 e 139), veio aos autos à fl. 147.

Recebida a denúncia em 19.01.2022 (fls. 157/159), os acusados foram citados pessoalmente (fls. 186 e 213) Em audiência, foi colhida prova oral e os réus interrogados (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição de GABRIEL por falta de provas. Subsidiariamente em relação a ele, e como pedido principal quanto ao corréu NATANAEL, a fixação da pena-base no mínimo legal, apontando ser a reincidência resquício do direito penal do autor, não se operando dupla majoração da pena pelos maus antecedentes e reincidência, em relação a NATANAEL; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas; a aplicação do art. 49, do Código Penal, no tocante à multa, por inconstitucional a previsão da lei de tóxicos; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O corréu GABRIEL, interrogado em juízo, confessou que na data conduziu o veículo ventilado, a pedido de NATANAEL, para transporte da droga para fins de tráfico, obtendo o entorpecente em São José dos Campos, sendo presos quando retornaram para Monteiro Lobato. Não adquiriu droga na oportunidade para seu uso, que é feito eventualmente (arquivo digital).

NATANAEL, em juízo, também confessou a prática do tráfico, dizendo que obteve a droga em São José dos Campos para venda em Monteiro Lobato. Alugou o veículo por R\$ 60,00, pedindo para GABRIEL dirigi-lo, sabendo ele o motivo da viagem. Ele aproveitou para comprar para si duas pedras de crack, apreendidas pela polícia mas não apresentadas na delegacia (arquivo digital).

Os policiais militares LUIZ AUGUSTO VIOLA DA SILVEIRA SALES e REGINALDO MALTA DOS SANTOS, ouvidos em juízo, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram que comunicados que o veículo ventilado transportava droga de São José dos Campos, abordaram-no em Monteiro Lobato, apreendendo em seu interior a droga e dinheiro ventilados, confessando os réus o transporte (arquivo digital).

O laudo de fls. 82/83 confirma que as substâncias apreendidas cuidam-se de cocaína que, como se sabe, é droga.

O telefone celular apreendido foi submetido à perícia (fls. 153/156).

A confissão dos réus, aliada à palavra dos policiais militares, que após receberem notícia anônima de tráfico de entorpecentes, abordaram os acusados, apreendendo, no interior do veículo em que se encontravam, expressiva quantidade e variedade de drogas (37,27g de cocaína, em 51 pinos plásticos; e 3,6g de crack, em 25 pedras), além de dinheiro (R\$ 20,00), elementos esses aliados à prova pericial, comprovam, à saciedade, que os réus transportavam e traziam consigo, a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação dos réus nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo

que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta aplicar as reprimendas.

I- Corrêu GABRIEL

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada de relevo há acerca de sua personalidade ou conduta social.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e as consequências do delito foram comuns (37,27g de cocaína, em 51 pinos plásticos; e 3,6g de crack, em 25 pedras).

A vítima é o Estado.

Diante desse quadro, em que são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não há agravantes.

Deixo de considerar a atenuante da confissão espontânea, visto que a pena-base foi fixada no mínimo abstratamente cominado, não podendo, nesta fase, vir alguém.

Inexistem causas de aumento.

Como o réu é primário, de bons antecedentes, não havendo provas de que se dedique a outras atividades criminosas ou integre organizações desta natureza, reduzo as reprimendas de metade (§ 4º do art. 33), ficando as penas definitivamente estabelecidas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

A redução deu-se neste importe em razão tratar-se de tráfico intermunicipal, perpetrado em concursos de agentes.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o aberto (art. 33, parágrafo 2º, 'c' e parágrafo 3º, do Código Penal).

Anote-se que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (§ 5º do art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19).

Presentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal, substituo, na forma do parágrafo 2º da mesma disposição, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser discriminada, nos termos do art. 46 do Código Penal, pelo Juízo da Execução, facultado seu cumprimento em metade do tempo da pena privativa de liberdade (art. 46, parágrafo 4º, do Código Penal), e 10 dias-multa, o unitário no piso legal,

pelas razões já expostas. Estas são as reprimendas mais adequadas à hipótese.

II- Corréu NATANAEL

O réu possui antecedentes criminais e é reincidente. A condenação referente ao processo nº 0781113-38.2009, da 1ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 05.08.2014 e para a Defesa em 08.10.2014 (fl. 51), é utilizada, logo, nesta etapa, e a condenação referente ao processo nº 0001596-15.2015, da 3ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 25.11.2016 e para a Defesa em 04.09.2017 (fl. 50) posteriormente na consideração da reincidência, a não caracterizar bis in idem.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“(...)Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas (...). Recurso ordinário ao qual se nega provimento”. (RHC 92611, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Anoto, por oportuno, não ter decorrido o lapso depurador da condenação referente ao processo n. 0781113-38.2009, pois em cumprimento de pena (fl. 60).

Já a condenação anterior transitada em julgado referente ao processo nº 0004469-27.2011, da 3ª Vara Criminal local, cuja pena privativa de liberdade foi declarada extinta pelo cumprimento em 09.03.2016 (fl. 111) não forja reincidência, na forma do art. 64, I, do Código Penal (anotando que, a meu ver, não há informações suficientes quanto à pena de multa de modo a se concluir não ter sido também extinta). Seria a meu juízo desarrazoado desconsiderar a condenação para efeito de reincidência e sopesá-la na análise dos antecedentes do acusado. De fato, o Direito Penal moderno não compactua com máculas perenes, vigendo, atualmente, o princípio da temporariedade dos antecedentes.

Assim a jurisprudência:

“(...) Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação do princípio da razoabilidade” (HC 110191, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

“EMENTA: PROCESSO CRIMINAL. Suspensão condicional. Transação penal. Admissibilidade. Maus antecedentes. Descaracterização. Reincidência. Condenação anterior. Pena cumprida há mais de 5 (cinco) anos. Impedimento inexistente. HC deferido. Inteligência dos arts. 76, § 2º, III, e 89 da Lei nº 9.099/95. Aplicação analógica do art. 64, I, do CP. O limite temporal de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, aplica-se, por analogia, aos requisitos da transação penal e da suspensão condicional do processo”(HC 86646, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, julgado em 11/04/2006, DJ 09-06-2006 PP-00018 EMENT VOL-02236-02 PP-00217 RTJ VOL-00200-02 PP-00933 LEXSTF v. 28, n. 332, 2006, p. 406-414 RT v. 95, n. 853, 2006, p. 504-507 RMDPPP v. 2, n. 12, 2006, p. 83-88).

Saliento, por oportuno, não haver transitado em julgado o v. acórdão do Supremo Tribunal Federal acerca do tema 150, com repercussão geral, não sendo, por ora, vinculante.

Nada de relevo há acerca de sua personalidade ou conduta social.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e as consequências do delito foram comuns (37,27g de cocaína, em 51 pinos plásticos; e 3,6g de crack, em 25 pedras).

A vítima é o Estado.

Diante desse quadro, em que não são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) não é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea, valioso meio de prova que confere ao julgador a certeza moral de uma condenação.

Aliás, a atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, tendo a Corte Superior decidido a matéria em recurso especial submetido ao procedimento previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil/73:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido" (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Registro que a previsão de reincidência como agravante é plenamente constitucional, atendendo antes aos ditames de plena individualização da pena.

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sessão do Pleno, após reconhecer a repercussão geral da matéria:

"Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada." (HC 93815, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

Não há causas de aumento a serem consideradas.

Anoto que devido à reincidência do réu, inaplicável a minorante do § 4º do art. 33, norma esta que atende a todos os princípios jurídico-penais, sendo plenamente válida, ficando as penas supracitadas definitivamente estabelecidas.

O regime inicial de cumprimento de pena, ante sua quantidade e reincidência, é o fechado (art. 33, §2º, 'a' e § 3º, do Código Penal), conclusão não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas seja pela mera quantidade de pena aplicada, seja pela reincidência.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar:

a) GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (regime aberto), além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, o unitário no piso, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, nos termos acima expostos;

b) NATANAEL DOS SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (regime inicial fechado), além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Autorizo a incineração das drogas, devendo ser observados os parágrafos 1º e 2º do art. 32 da Lei nº 11.343/06.

Decreto a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido nestes autos.

Em relação a GABRIEL, ausentes os requisitos da prisão preventiva, poderá apelar em liberdade (anotando-se já se encontrar nessa condição).

NATANAEL deverá permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade, sendo insuficientes medidas diversas. Recomende-se onde se encontra.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 10 de março de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA